



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2012.0000522602

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação nº 0002184-85.2010.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOSÉ FRANCISCO MARINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ajustar as penas e condenar o apelante definitivamente ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 217-A, cc. o art. 69, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores TOLOZA NETO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E LUIZ ANTONIO CARDOSO.

São Paulo, 2 de outubro de 2012.

FERNANDO SIMÃO
RELATOR



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Assinatura Eletrônica

VOTO nº 3923

APELAÇÃO nº 990.10.574966-6

COMARCA: Barra Bonita – 2ª Vara Judicial

Apelante: JOSÉ FRANCISCO MARINHO

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Estupro contra vulnerável – Preliminar - Nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência. Mérito - Negativa da autoria isolada – Declarações das vítimas coerentes com outras provas produzidas sob o contraditório – Afastada a teste da síndrome da alienação parental até porque uma das vítimas não tinha parentesco com o apelante – Parcial provimento apenas para ajustar a pena base ao mínimo – Fundamentação na sentença limitando-se a transcrever trecho da denúncia para justificar a majoração – Deficiência já que o correto seria fundamentar em dados objetivos relacionados ao art. 59 do CP, tais como circunstâncias e consequências do delito – Ajustadas as penas e mantida a condenação.

Adotado o relatório da r. sentença de fls. 144/147, acrescenta-se que o réu **JOSÉ FRANCISCO MARINHO** foi condenado, como incurso, por duas vezes, no art. 217-A do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.

Regularmente processado o recurso, nesta instância, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo (fls. 181/182).

É o relatório.

Primeiramente, é de se rebater os argumentos trazidos pela nova defensoria do réu, ao ensejo da sustentação oral.

Nenhuma irregularidade existe na representação processual pela defesa técnica durante todo o curso do processo, mesmo porque, o réu que tem formação universitária, compareceu às audiências acompanhado de causídico de sua escolha, tanto é que conjuntamente assinaram todos os termos lavrados pelo Juízo. Além do mandato com amplos poderes da cláusula *ad juditia*, também houve a formalização no termo, pelo que se domina constituição de Advogado *apud acta*.

Quanto a não ter ocorrido reperguntas às testemunhas de defesa, foi opção técnica defensiva, o que deve ser respeitado. Sabe-se que, por vezes, diante de quadro probatório tão desfavorável ao réu, reperguntas poderiam prejudicá-lo ainda mais. Melhor, então, não fazê-lo, a critério do defensor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Também, não se vislumbra prejuízo ao réu, não ter a defensoria inovado em seus argumentos por ocasião das razões de apelação. Simplesmente ficou fiel à tese anteriormente levantada para ser reapreciada no órgão colegiado.

Nenhuma mácula existe no julgado, com perfeita correlação entre fatos narrados na denúncia e decisão de primeiro grau, a par do que também foram observados os critérios técnicos para a fixação da pena.

A alegação de cerceamento de defesa a ensejar prejuízo para o réu, como alegado na sustentação oral, não existiu, refutando-se, portanto, a preliminar trazida na inovação em sessão de julgamento.

A r. sentença monocrática merece ser mantida, em parte, por seus próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor, merecendo somente pequeno reparo na pena.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo ser inverídica a acusação. Sua negativa, porém, não convence, pois restou isolada nos autos, pois a prova produzida sob o crivo do contraditório (depoimentos colhidos através do sistema audiovisual) se mostrou isenta e absolutamente incriminadora, senão vejamos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

A vítima **Jheniffer Sanches Marino**, filha do réu, de 09 anos de idade à época (certidão de nascimento de fls. 13), ouvida em juízo, narrou detalhadamente como os atos libidinosos foram praticados pelo seu pai contra ela e sua amiga Shaiene, de mesma idade (certidão de nascimento de fls. 12). Contou que, “por várias vezes, muitas vezes”, o réu mandava que ela colocasse “camisinha no nenê”, referindo-se ao pênis, além de mandá-la “mexer e bater” no órgão sexual. Disse que nunca foi tocada pelo pai, mas tanto ela quanto Shaiene tocaram no pênis do réu “muitas vezes” – o genitor “ficava na cama e a gente mexia uma vez de cada”. Disse, também, que seu pai colocava filmes pornográficos para ela assistir e que ele ficava pelado na piscina.

A vítima **Shaiene Cristina da Silva Oliveira**, por sua vez, disse que o réu colocava filme “que mostrava coisa que não pode, de gente pelada” para ela e sua amiga assistirem e que ele nadava pelado na piscina. Contou, ainda, que ele mandava que ela passasse “creme no pipi e a Jheniffer ajudava”, apesar de terem nojo, e que umas 10 vezes, falou para passarem a mão no “negócio dele”. Narrou que chegou a se sentar no colo do acusado quando ele estava sem roupa.

Importante frisar que em se tratando de crime contra os costumes, a fala da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece credibilidade.

A doutrina afirma que “(...) *há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, p. 343).

Nesse sentido:

ESTUPRO - TENTATIVA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SEGURAS E COERENTES - OCORRÊNCIA DO DELITO. Nos crimes contra os costumes, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima, corroborados por elementos probatórios dos autos, é suficiente para embasar o decreto condenatório.

(Apelação 9115810-89.2008.8.26.0000, rel. Willian Campos, 4ª Câmara de Direito Criminal, data do julgamento: 29/03/2011)

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. Violência presumida. Arguição de nulidades processuais por cerceamento de defesa. Inocorrência. Não comprovação de prejuízo. Matéria preliminar afastada. Prova robusta da autoria e da materialidade. Palavra da ofendida coerente e em harmonia com o restante da prova. Condenação inafastável. Pena mínima, com imposição do regime semiaberto, imodificável pela falta de apelo ministerial. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar.

(Apelação 0013456-64.2008.8.26.0510, rel. Tristão Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Criminal, data do julgamento: 07/04/2011)

Mas não é só. A robustecer o quadro probatório estão ainda os firmes depoimentos das testemunhas de acusação, que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

corroboraram as declarações prestadas pelas vítimas.

Josiane Pereira Sanches, mãe da vítima, confirmou que sua filha contou para a avó o que houve entre ela e seu pai na edícula dele durante 3 anos, em domingos alternados. Disse que o réu, além mandar a filha colocar camisinha e masturbá-lo, colocava filme pornô para sua filha e as amigas assistirem, inclusive de “mulher transando com cavalo”. Narrou que Shaiene lhe teria contado que o réu a mandava sentar no colo dele e a mexer no “nenê”, referindo-se ao pênis.

Caroline Fernanda Bruno de Oliveira, de 17 anos de idade, afirmou ter ido à edícula do réu, por várias vezes, sempre aos domingos, junto com Jheniffer. Disse que quando estavam na piscina o acusado “se exibia na frente da filha” e, durante a brincadeira de “pega-pega”, ele corria, deixava a toalha cair e ficava pelado. Contou sobre o fato do réu esconder moeda “nas partes dele”, pedindo para que elas procurassem. Disse que nunca deixou Jheniffer “relaxar” quando estava por perto e que não contou os fatos para ninguém por conta de Jheniffer, que se dizia ameaçada pelo pai.

Andreza de Oliveira Barreto, de 12 anos de idade, por fim, afirmou ter frequentado a edícula do réu para nadar. Disse que ele colocava moeda na cueca e mandava que elas, inclusive a própria filha, procurassem, e que quando estavam na piscina eram chamadas pelo réu para brincarem de “pega-pega”, oportunidade em que ele corria, deixava a toalha cair e ficava pelado. Narrou, também, que ele colocava filme



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

pornográfico quando estavam na edícula e que Jheniffer era muito ameaçada pelo pai.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, por outro lado, não foram suficientes para afastar a responsabilização do recorrente, pois elas procuraram apenas enunciar a sua boa conduta social.

Não há se falar na ocorrência da “síndrome da alienação parental”, diante do relato da também vítima Shaiene, que não guarda qualquer vínculo familiar com o réu, e dos seguros depoimentos prestados pelas testemunhas Caroline e Andreza, que chegaram a presenciar as condutas libidinosas por parte do réu. Ademais, o próprio réu disse em seu interrogatório judicial que era ótimo o seu relacionamento com sua filha, o que afasta a possibilidade de que a criança estivesse sendo treinada por sua mãe para romper os laços afetivos com o pai, tal como sustentado pela douda defesa.

Assim, a autoria é certa, enquanto a materialidade decorre do boletim de ocorrência de fls. 3/5 e da prova oral colhida. Equivocada a alegação da defesa no sentido de que o laudo de exame de corpo de delito não atestou qualquer violência sexual. A uma, porque inexistente nos presentes autos qualquer laudo pericial. A duas, porque, caso existente, não poderia mesmo o laudo atestar qualquer tipo de violência sexual, haja vista que as próprias vítimas narraram que elas nunca ficaram despidas, mas tão somente o réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.

A causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal restou corretamente reconhecida, pois o réu é pai da vítima.

Fique registrado que o réu foi bastante beneficiado com a não aplicação da regra do crime continuado quanto a cada uma das vítimas, pois, efetivamente, em relação a elas, estavam presentes os pressupostos do art. 71 do Código Penal. Com efeito, o réu constrangeu as vítimas, por várias vezes, à prática de atos libidinosos – aos domingos alternados, nos dias de visita deferida judicialmente. Assim, caso fosse aplicada a continuidade delitiva para uma e para outra vítima, e depois somadas as penas pelo concurso material, porque, repita-se, os crimes foram praticados contra ofendidas diversas, a somatória superaria os 20 anos de reclusão. Superada essa observação, mesmo porque não houve recurso pelo Ministério Público, por deficiência de fundamentação para o aumento da pena base, é preciso ajustá-las ao mínimo.

É que no juízo de primeiro grau, para justificar a majoração da pena, assim explicitou: *“considerando que o réu, como visto, além de praticar os atos libidinosos contra a vítima, também costumava se apresentar nu e exhibir filmes pornográficos”*. Limitou-se a praticamente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

repetir termos da denúncia, quando, na verdade, a majorante até poderia ter lugar com base em circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, afirmando-se, fundamentadamente, acerca de circunstâncias do delito, principalmente porque se aproveitava de fato de estar sozinho com a filha e outra criança que a acompanhava, em dia de visita devidamente regulamentada; as consequências nefastas para toda a vida das crianças também não poderiam ser esquecidas. Todavia, não foi isso que se fez e não se pode fazer agora, porquanto se trata de recurso exclusivo da defesa.

Assim, a pena base em relação a cada vítima fica ajustada para o mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão. Persiste em relação à vítima Jheniffer o aumento na metade, nos termos do inciso II do art. 226 do Código Penal, de modo que, em relação a ela, a condenação atinge 12 (doze) anos de reclusão, o que somado aos 08 (oito) anos de reclusão em relação à vítima Shaiene, resulta a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

O regime inicial fechado para o cumprimento da pena é o adequado, porquanto o crime atribuído ao apelante é hediondo.

A propósito, já se decidiu:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. HEDIONDEZ DO DELITO. NÃO AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO POR LEI. LEI 11.464/2007. RECURSO PROVIDO.

I. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda quando cometidos em sua forma simples ou com violência presumida, enquadram-se na definição legal de crimes hediondos,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

recebendo essa qualificação ainda quando deles não resulte lesão corporal de natureza grave ou morte da vítima.

II. Com o advento da Lei 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, ficou estabelecido o regime inicialmente fechado de cumprimento das penas por crimes ali previstos.

III. Precedentes.

IV. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.

(REsp 1205790 / RS, rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, data do julgamento: 01/03/2011)

Destarte, a bem lançada decisão monocrática merece reparo no tocante às penas.

Ante o exposto, por meu voto, afastada a preliminar, CONHEÇO e **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso de apelação, para ajustar as penas e condenar o apelante definitivamente ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 217-A, cc. o art. 69, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

FERNANDO SIMÃO
Relator